

1502579-35.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... condenado por três atos análogos ao tráfico de drogas na seara da infância, o último refere-se ao ano 2019 (fl. 30). Essa cronologia é um indicador de que o réu seja pessoa dedicada ao tráfico de drogas de longa data.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502579-35.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502579-35.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

CLEITON JOSE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

WAGNER SANTOS DA SILVA e CLEITON JOSE DA SILVA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no 5 de novembro de 2021, por volta das 1h47, na Rua Sibéria, 20, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, guardavam e mantinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 129 porções de cocaína e 28 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 5), assim como o laudo de constatação (fls. 21/23) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/109).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fl. 112) e apresentaram defesa preliminar (fls. 122/134). Em 4 de maio de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 143/144). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) WAGNER SANTOS DA SILVA e CLEITON JOSE DA SILVA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 5 de novembro de 2021, por volta das 1h47, na Rua Sibéria, 20, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, guardavam e mantinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 129 porções de cocaína e 28 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento viram os réus perto de uma praça de lazer e eles tentaram fugir da aproximação da viatura. Realizada a abordagem, na roupa íntima de Cleiton foi encontrada uma sacola com as drogas acima discriminadas e R\$ 75,00. Sob a posse do réu Wagner foi localizada a quantia de R\$ 100,00.

A existência das drogas é certa, pois foram juntados aos autos do presente feito o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

A dúvida diz respeito à destinação da droga, se para consumo próprio ou para consumo alheio, assim como à autoria.

A quantidade e a diversidade de espécies de drogas indicam que o destino da droga era o consumo alheio. As provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório, denotam que houve mesmo tráfico de drogas, mas, por haver dúvida quanto à prática do crime por parte do réu Wagner, ele deve ser absolvido. Apenas o réu Cleiton deve ser condenado.

Com efeito, o réu Cleiton admitiu em juízo a prática do crime. Disse que estava traficando mesmo, mas sozinho.

Essa confissão está em harmonia com a negativa do réu Wagner. Ele disse que estava voltando para casa do trabalho que realiza informalmente em um lava-rápido. Havia recebido R\$ 115,00 por conta de 3 dias e meio de trabalho. Havia gasto parte dele com comida. Foi abordado no caminho. Não havia nem sequer visto o corréu. Não correu.

Uma vez que um réu admite a prática do crime em juízo, mas sozinho, e o outro a nega, a prova da acusação precisaria ser clara quanto à prática do crime por parte de ambos, a corroborar a confissão do primeiro, mas, especialmente, de forma mais consistente, com relação ao segundo.

Não foi isso que ocorreu. O Ministério Público não se desincumbiu desse ônus.

Isso porque os dois guardas civis que efetuaram a prisão dos réus disseram claramente em juízo que assim que os réus correram assim que os viram. No entendimento do STJ, o que venho adotando por segurança jurídica e igualdade material, o simples correr não é atitude suspeita a justificar o ingresso no domicílio. Mas isso não significa que não se trate de algo suspeito, pois "quem não deve não teme", já diz o ditado popular. Natural, portanto, que tenham sido perseguidos e abordados.

Ocorre que, com o réu Wagner nada foi encontrado a não ser R\$ 100,00. Não havia drogas com ele. Todas as drogas estavam com o corréu Cleiton.

É cediço que traficantes que atuam conjuntamente se dividem nesse mister, por isso é possível que estivessem atuando juntos. No entanto, se com o réu Wagner não havia drogas, para que se possa dizer cabalmente que ele estivesse traficando, seria preciso demonstrar que ele atuava mesmo em conjunto com Wagner. Neste ponto é que a acusação falhou.

É que o réu Wagner negou ter corrido. Os guardas disseram que ele o fez, mas são palavras de uns contra a de outro. Mas mesmo que ele tenha corrido. Se correu, mas antes disso não foi visto fazendo nada que indicasse que estava atuando no tráfico, o que restou contra ele é a suspeita decorrente da corrida. Nada mais. Ele não foi visto sequer conversando com o corréu Cleiton antes de correr. Não foram vistos atendendo usuários de drogas antes de correr, nem trocando dinheiro ou drogas consigo. Tampouco foram vistos indo a algum lugar juntos, onde haveria drogas. Cuida-se de algo muito frágil para que alguém seja levado à prisão.

É possível que o réu Wagner estivesse ajudando o corréu Cleiton no tráfico? Em tese, sim. Mas, no plano concreto, pelas provas coligidas aos autos, sobretudo em juízo, isso restou duvidoso. E na dúvida ele deve ser absolvido, para que não se corra o risco de condenar um inocente, apenas porque algumas circunstâncias, especialmente de caráter histórico, lhes são desfavoráveis.

Bem verdade que ele não comprovou a origem lícita do dinheiro que tinha consigo, mas isso é uma falha da defesa que não compromete a sua absolvição, porquanto cabe à acusação provar a culpa, não ao réu a inocência. Ademais, o valor não é tamanho a ponto de se dizer que a sua origem é certamente ilícita.

Acolho a acusação também no que tange ao artigo 40, inciso III, da Lei n.

11.343/06, pois a lei dispõe ser causa de aumento de pena o tráfico de drogas nas imediações de área de lazer. Consta da lei o seguinte: "entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza".

De acordo com o léxico, o recinto não precisa ser um local fechado. Basta que ele seja delimitado. É o caso. As imagens apresentadas mostram que ao lado do local em que o réu Cleiton traficava havia uma praça, inclusive com quadra de futebol e brinquedos infantis. Os guardas ainda disseram em juízo que havia crianças brincando no momento da prisão.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o crime praticado pelo(a) ré(u) teve como objeto 157 porções de drogas, entre maconha e cocaína. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confira-se o posicionamento do C. STJ a respeito:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato. Sem agravantes a considerar em relação ao réu, torno a pena dele ao mínimo legal, 5 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena noto que está presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei acima. Uma vez que a praça de lazer estava próxima e que, mais do que poder haver pessoas no local, havia, de fato, crianças, brincando, entendo por bem aumentar a pena em 1/4.

Não há causas diminuição de pena na terceira fase. Embora o réu seja primário, já respondeu e foi condenado por três atos análogos ao tráfico de drogas na seara da infância, o último refere-se ao ano 2019 (fl. 30). Essa cronologia é um indicador de que o réu seja pessoa dedicada ao tráfico de drogas de longa data.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressaltado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos"

(STJ – 3ª Seção, EREsp 1916596 / SP, rel. P/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.09.2021, DJ 04.10.2021)

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) ré(s) e a pena de multa, que deve seguir os mesmos parâmetros, ficam consolidadas em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de 620 dias-multa.

O réu é primário, por isso poderia iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. No entanto, o que constou da última fase de aplicação da pena indica que ele não tem condições de iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando que o fechado, pois assim é recalcitrante e não surtiram efeitos as sanções que lhe foram aplicadas anteriormente, ainda sob o prisma da infância e juventude. Considerando que o valor da pena de multa deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantendo-a no menor valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

Absolver o réu WAGNER SANTOS DA SILVA, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e,

Condenar o réu CLEITON JOSE DA SILVA, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Considerando o que foi dito por ocasião da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, deverá o réu Cleiton permanecer preso. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra.